

1500945-86.2022.8.26.0180

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... da ação penal. O crime de tráfico de drogas restou demonstrado pelos laudos periciais de fls. 137/139 e 170/172, bem como pela forma que as drogas estavam acondicionadas e variedade, além da quantidade de valores apreendidos, que caracteriza produto do tráfico. Os acusados admitiam a traficância, a ré alegou que por três vezes vendeu entorpecentes para o réu. Já Eder ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

1ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500945-86.2022.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500945-86.2022.8.26.0180

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225432/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 26835781 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2225432 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER MACIEL LOPES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Vistos.

SIDNEYA DE JESUS VICENTE e EDER MACIEL LOPES, ambos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em 17 de agosto de 2022, em horário não apurado, na Rua Edmundo Scanapieco, nº 69, Vila São Pedro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, os acusados associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Consta ainda que no dia 17 de agosto de 2022, pouco antes das 17h30, na Rua Edmundo Scanapieco, nº 69, Vila São Pedro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, SIDNEYA DE JESUS VICENTE entregou a EDER MACIEL LOPES 30 (tinta) porções de cocaína, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22 e, bem assim, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de Substância Entorpecente às fls. 137/139).

Consta também que na mesma data, por volta das 17h30, na Rua Francisco Alves Leitão, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, EDER MACIEL LOPES trazia consigo, para fins de tráfico, 30 (trinta) porções de cocaína, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22 e, bem assim, Auto de constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 74/75), tendo SIDNEYA DE JESUS VICENTE, concorrido de qualquer forma para a prática do crime. Consta mais, que nas mesmas condições de tempo, na Rua Edmundo Scanapieco, nº 69, Vila São Pedro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, SIDNEYA DE JESUS VICENTE, trazia consigo, para fins de tráfico, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, além de 107 (cento e sete) porções (pedras) de "crack" (feito à base de cocaína), drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22 e, bem assim, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de Substância Entorpecente às fls. 137/139).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 13 de outubro de 2022 (fls. 179/182).

Os corréus Eder e Sidneya foram regularmente notificados (fl. 175), apresentando defesa prévia em comum às fls. 149/154.

No curso da instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa, seguindo-se do interrogatório dos acusados, tudo por mídia audiovisual.

Em alegações finais o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. O crime de tráfico de drogas restou demonstrado pelos laudos periciais de fls. 137/139 e 170/172, bem como pela forma que as drogas estavam acondicionadas e variedade, além da quantidade de valores apreendidos, que caracteriza produto do tráfico. Os acusados admitiam a traficância, a ré alegou que por três vezes vendeu entorpecentes par ao réu. Já Eder confessou que os entorpecentes destinavam a venda e que foi a primeira aquisição. Os policiais deram conta de denúncias do envolvimento da ré do intenso comercio de drogas na residência da acusada. Neste contexto, basta para condenação. Lado outro, quanto ao crime de associação ao tráfico o depoimento dos policiais relata preparo e separação dos entorpecentes na residência da ré e o relato da ré que admitiu que era a terceira vez que fornecia drogas ao acusado Eder, impondo condenação dos réus, visto que ficou comprovado o vínculo associativo duradouro caracterizadores da associação. Quanto à reprimenda, na primeira fase, impõe-se consignar que a ré Sidneya é primária e não possui maus antecedentes (fl. 50), enquanto o réu Eder é reincidente e possui maus antecedentes (fls. 43/47). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência para o réu Eder. Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quanto à ré Sidneya. Imposição de regime inicial fechado para ambos os réus, sem substituições.

A defesa dos acusados, por sua vez, alegou que os Policiais Militares entraram de maneira ilegal na casa de Sidneya, de fato, a ré estava na posse de drogas e eles sabiam disso, entretanto a prisão da ré não poderia ter ocorrido da maneira em que se deu, pois os policiais entraram na residência da ré a noite, sem mandado de prisão, e sem que ela estivesse em estado de flagrância, pois, este já havia cessado. De acordo com as imagens juntadas podemos verificar que de fora do imóvel não é possível visualizar o interior da residência, logo, impossível que os policiais tivessem visto a ré manuseando drogas dentro do imóvel, o que resulta em prova ilícita, devendo as provas obtidas na residência da acusada seres desentranhadas dos autos. O crime de associação ao tráfico não restou configurado, não restou demonstrada a existência de vínculo associativo entre os corréus, ou ainda qualquer tipo de habitualidade, estabilidade e organização, tratando-se de mera convergência ocasional de condutas. Quanto a dosimetria, Eder confessou e faz jus atenuante. Devendo ser aplicada pena mínima para Eder. Quanto a ré deve destacar que as provas foram obtidas mediante violação do domicílio, há imagens nos

autos que mostram o local, impossível visão dela do interior da casa dela. O estado de flagrância inicial, esse era o flagrante do momento de entrega das drogas para Eder, retornaram posteriormente. Depois de cessado o momento de flagrância. Quanto dosimetria absolvição do art. 35 por ausência de provas. Absolvição do tráfico por artigo 386, VII. Requer expedição de alvará em favor da ré porque é tecnicamente primária, incidindo §4º do artigo 33, impondo pena em regime aberto. Requereu, portanto, a absolvição de Sidneya pelo crime de tráfico de drogas, eis que as provas que sustentam sua condenação são ilícitas, bem como a absolvição de ambos os réus pelo crime de associação ao tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Afasto a preliminar de nulidade arguida pela defesa, pois não há que se falar em nulidade da prova obtida com a prisão em flagrante. A prisão foi realizada no domicílio do réu e nenhuma nulidade decorre disso, eis que estava em flagrante delito, exceção feita à garantia constitucional. O texto constitucional já contempla a exceção à regra de forma clara no artigo 5º, XI da CF, pois não existem direitos absolutos.

Art. 5º (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Nos termos do artigo 302 do CPP, está em flagrante não apenas aquele que está cometendo a infração pena, mas também aquele que acaba de cometê-la ou é encontrado logo depois com objetos que faça presumir ser autor do delito. Portanto, ainda que os policiais não tenham realizado a prisão em flagrante da ré durante o cometimento da infração, quando entregou drogas para Eder, ela tinha acabado de cometer a infração e ainda estava na posse de entorpecentes. Tratando-se de crime permanente, não há que se afastar a legalidade do flagrante das provas decorrentes.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 36/37), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 74/75), pela guia de depósito judicial (fl. 133), pelo laudo pericial (fls. 137/139), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, é certa.

Em solo policial (fl. 23), o acusado Eder manifestou o desejo de exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e só se manifestar em juízo.

Em juízo disse realmente veio de MG porque estava com dívida em MG. Comprou as drogas e se pretende vender mesmo, estava vendendo drogas. É usuários e vendia um pouco também. Estava há quatro dias na cidade, não foi abordado anteriormente. Estava no tráfico. Trabalhava de pintor, estava sem trabalhar e sem renda. Tem 36 anos. Foi a única vez que comprou droga dela e pagou R\$ 200,00, venderia por R\$ 10,00 cada uma, totalizando R\$ 300,00.

Em solo policial (fls. 24/25), a acusada Sidneya disse que tem um filho de três anos de idade, o qual está sob os cuidados da tia paterna, a Sra. Cilene Vicente. Que faz consumo de drogas, cocaína; Que atualmente está trabalhando na roça apanhando café; Que não sabe o nome da Fazenda onde está trabalhando. Disse que conhece Eder Maciel Lopes há poucos dias; Que Eder veio de Mogi-Guaçu e se mudou para o bairro onde mora, Vila São Pedro; Que há três dias começou a conversar pessoalmente com Eder; Que na data de hoje, pela tarde, estavam no "Bar do Nando", oportunidade em que Eder lhe pediu um favor; Que Eder lhe pediu para "segurar uma droga por meia hora"(sic); Que lhe pagaria R\$100,00 (cem reais) por esse favor;

Relata que sabia que Eder destinaria a referida droga para comércio, visto que já tomou conhecimento de que ele trafica. Conta que aceitou fazer esse favor para Eder; Que foi para casa e algum tempo depois Eder bateu em seu portão entregando-lhe uma sacola contendo as referidas drogas; Informa que aproximadamente dez minutos depois a polícia militar entrou em sua casa; Que foi pega com a mão na sacola; Que sequer chegou a contar a quantidade de drogas que havia no interior da sacola; Que o dinheiro que foi encontrado em cima do fogão também lhe foi entregue por Eder, o qual também disse que era para segurar por algum tempo. Relata por fim que já tem passagem por tráfico de drogas por fato ocorrido há 1 (um) mês e que está de liberdade provisória.

Em juízo disse confessa que entregou para o Eder, vendeu para ele. A ré que estava vendendo. Confessa que essas drogas foram apreendidas. Tentou dispensar as drogas. Já foi presa por tráfico e saiu na eficiência de custódia. Tem 21 anos, estudou até primeiro ano, trabalhava na roça e dois dias da semana fazia faxina. Tinha visto ele duas vezes só, ele já era conhecido como comprador. Não sabia se ele ia vender, ele comprou drogas umas três vezes. Não se lembra as quantidades anteriores. Disse que estava na cozinha quando os policiais entraram. Do interior da minha casa não da pra ver a rua porque o portão é de chapa, não há buraco no portão.

Em solo policial (fls. 05/06), o Policial Militar Ricardo Alexandre Simionato disse que estava de serviço com seu parceiro de farda o CBPM Bezerra no município de Espírito Santo do Pinhal; Que há tempos recebem denúncias de que a pessoa de Sidneya armazena drogas em sua casa para distribuí-las aos traficantes do bairro Vila São Pedro; Que esse fato inclusive foi pauta da reunião do CONSEG da cidade de Espírito Santo do Pinhal, tendo sido solicitado às forças policiais uma atenção maior a essa questão. Relata que hoje, na oportunidade, estabeleceram-se em um ponto estratégico próximo à casa de Sidneya, onde conseguiram visualizar toda a movimentação no referido recinto; Conta que em determinado momento a pessoa Eder Maciel Lopes bateu no portão de Sidneya; Que Eder foi atendido por Sidneya, que já estava com uma sacola plástica na mão; Que conversaram pouco tempo, tendo Sidneya colocado a mão dentro da referida sacola, retirado dois kits de cocaína embalados em plástico transparente e os entregado a Eder; Que Eder saiu em direção a um ponto de venda de droga, praça pública conhecida como "Miolo", onde foi abordado na Rua Francisco Alves Leitão; Conta que na oportunidade, ao ser abordado, Eder colocou no interior da boca os dois kits de cocaína que havia acabado de pegar; Informa que cada kit continha 15 (quinze) eppendorfs de cocaína, totalizando 30 (trinta); Submetido a busca pessoal, também foi encontrado com Eder, dentro de sua pochete, o valor de R\$72,00 (setenta e dois reais) em notas diversas e um aparelho celular da marca Samsung; Na oportunidade Eder confessou ter pegado a droga com Sidneya e que iria comercializar cada eppendorf pelo valor de R\$10,00 (dez reais). Diante desses fatos, rumaram para a casa de Sidneya; Conta que o portão de Sidneya, por conta do trinco, permite visualização de quem está de fora do imóvel; Que embora já tivessem visto Sidneya momentos atrás em situação flagrancial entregando drogas a Eder, pela fresta do portão, novamente visualizaram Sidneya com drogas; Sidneya estava no corredor da casa, mexendo em um kit de drogas dentro da mesma sacola acima referida; Esclarece que nesse momento, evidenciada a fundada suspeita, ingressaram no imóvel; Relata que Sidneya correu para o interior da casa e tentou dispensar a droga pelo vaso sanitário, todavia conseguiram impedir o intento; Que retiraram do vaso a sacola contendo: 2 (dois) kits contendo cocaína, sendo um com 15 (quinze) eppendorfs e outro com 16 (dezesseis) eppendorfs e mais 11 (onze) kits de crack, sendo que 10 (dez) destes contendo 10 (dez) pedras e 1 (um) kit contendo sete pedras; Ademais, em cima do fogão da cozinha de Sidneya, encontraram o valor de R\$439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em notas diversas e um aparelho celular Moto G; Diante dos fatos, conduziram Sidneya e Eder em viaturas distintas até o pronto atendimento municipal de Espírito Santo do Pinhal e posteriormente, também separados, até o presente plantão policial. Em tempo, esclarece que no momento da prisão de Sidneya, encontrava-se presente na casa o filho dela de três anos de idade, o qual ficou aos cuidados da tia paterna (Sra. Cirlene Vicente) a pedido da própria.

Em juízo disse a PM já tinha recebido diversas denúncias de que Sidneya tinha

alugado um imóvel e estava guardando drogas para serem vendidas na Vila São Pedro. Segundo a denúncia, ela recebia as drogas, dividia em kits e depois distribuía a outros traficantes. Na data dos fatos estava observando a residência quando Eder foi a residência dela, Eder chegou a casa dela bateu ao portão e foi atendido por ela. Ela trazia nas mãos uma sacola, retirou dois kits e entregou a Eder. De onde estavam dava para ver, era nítido porque o plástico era transparente. Eder foi abordado, colocou kits no interior da boca. Cada kit tinha 15 pinos de cocaína, totalizando 30 pinos de cocaína. Na pochete havia R\$ 72,00 e um celular, confessou ser proveniente tráfico. Ele confirmou ter pegado os kits com ela. Seguiram a casa de ela, por uma fresta do portão puderam ver que ela estava no quintal manuseando uma sacola com kits de crack e cocaína. Ela tentou dispensar as drogas no vaso sanitário. Ela foi presa, fizeram apreensão de cerca de 30 pinos de cocaína e mais de 100 pedras de crack; em cima do fogão havia R\$, foi apreendido também um aparelho de celular. Os relatos que foi pauta da reunião era relacionado a ré e sua residência, quanto a Eder ele já foi visto junto com a ré. Essas denúncias não faziam menção a Eder, mas apenas em relação a Sidneya, que recebia os kits, dividia e os entregava para os traficantes do bairro. A fresta utilizada para visualizar a ré foi pelo portão principal da frente. Ela estava no corredor quando foi visualizada manuseando as drogas.

Em solo policial (fls. 26/27), o Policial Militar Wellington Davanço Bezerra disse que estava em serviço com seu parceiro de farda o SDPM Simionato no município de Espírito Santo do Pinhal; Que não é de hoje que recebem denúncias de que a pessoa de Sidneya armazena drogas em sua casa para distribuí-las aos traficantes do bairro Vila São Pedro; Inclusive esse fato foi pauta da reunião do CONSEG da cidade de Espírito Santo do Pinhal, tendo sido solicitado às forças policiais uma atenção maior a essa questão. Cientes dessa reclamação, estabeleceram-se hoje em um ponto estratégico próximo à casa de Sidneya, onde conseguiram visualizar toda a movimentação no referido recinto; Em determinado momento a pessoa Eder Maciel Lopes bateu no portão de Sidneya e foi atendido por ela, que já estava com uma sacola plástica na mão; Sidneya e Eder conversaram pouco tempo, tendo Sidneya colocado a mão dentro da referida sacola, retirado dois kits de cocaína embalados em plástico transparente e os entregado a Eder; Após, Eder saiu em direção à um ponto de venda de drogas, na praça pública conhecida como "Miolo", onde foi abordado na Rua Francisco Alves Leitão; Ao ser abordado, Eder colocou no interior da boca os dois kits de cocaína que havia acabado de pegar; Cada kit continha 15 (quinze) eppendorfs de cocaína, totalizando 30 (trinta); Em busca pessoal, também foi encontrado com Eder, dentro de sua pochete, o valor de R\$72,00 (setenta e dois reais) em notas diversas e um aparelho celular da marca Samsung; EDER então confessou ter pegado a droga com Sidneya e disse que iria vender cada eppendorf pelo valor de R\$10,00 (dez reais). Diante disso, dirigiram-se para a casa de Sidneya; O portão de Sidneya, por conta do trinco, permite visualização de quem está de fora do imóvel; Embora já tivessem visto Sidneya momentos atrás em situação flagrancial entregando drogas a Eder, pela fresta do trinco do portão, novamente visualizaram Sidneya com drogas; Ela estava no corredor da casa, mexendo em um kit de drogas dentro da mesma sacola acima referida; Nesse momento, evidenciada a fundada suspeita, ingressaram no imóvel; Ao notar o ingresso, Sidneya correu para o interior da casa e tentou jogar a droga pelo vaso sanitário, entretanto conseguiram impedir; Retiraram do vaso a sacola contendo: 2 (dois) kits contendo cocaína, sendo um com 15 (quinze) eppendorfs e outro com 16 (dezesseis) eppendorfs e mais 11 (onze) kits de crack, sendo que 10 (dez) destes contendo 10 (dez) pedras e 1 (um) kit contendo sete pedras; Relata também que, em cima do fogão da cozinha de Sidneya , encontraram o valor de R\$439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em notas diversas e um aparelho celular Moto G; Por essas razões, conduziram Sidneya e Eder em viaturas distintas até o pronto atendimento municipal de Espírito Santo do Pinhal e posteriormente, também separados, até o presente plantão policial. Em juízo disse na data dos fatos estava de serviço com SD Simionato e PM Eleutério, já tinham recebido denúncias de que ela estava guardando drogas que eram fornecidas para serem traficadas na Vila São Pedro. Esse assunto já foi pauta do CONSEG. No dia dos fatos receberam novas denúncias. Já sabiam horário que ela fazia

distribuição, assim, fizeram breve acompanhamento quando visualizaram Eder mantendo contato com a ré no portão, recebendo dois kits de cocaína. Ele foi abordado a seguir. No interior da boca do réu localizaram 2 kits, contendo 15 pinos de cocaína cada um. Ele confessou que tinha recebido as drogas de Sidneya, que o dinheiro era proveniente do tráfico e que as drogas eram destinadas a venda. Retornaram à residência da ré, puderam visualizar ela no interior da residência manuseando drogas. Quando percebeu a presença dos policiais, ela tentou dispensar as drogas no vaso, sem sucesso. Nessa sacola localizaram 2 kits idênticos e mais 11 kits de crack, contendo mais de 100 pedras de crack; em cima do fogão havia caderno com anotações do tráfico e dinheiro. Ela confessou que estava distribuindo drogas no bairro e disse que no dia anterior tinha muito mais drogas. Na delegacia a Sidneya disse que a droga era do Eder, ele ficou em silêncio. Ela já tinha sido presa dias antes por tráfico de drogas. Avistou a ré pelo portão da frente, pelo buraco que há no portão.

Quanto ao delito de tráfico de drogas:

Os depoimentos dos Policiais Militares merecem toda credibilidade, foram firmes e coerentes, confirmaram que há tempos recebem denúncias dando conta que Sidneya armazena drogas em sua casa para distribuí-las aos traficantes do bairro Vila São Pedro. Na data dos fatos os policiais se estabeleceram em um ponto estratégico próximo à residência da acusada e puderam visualizar toda a movimentação no referido imóvel. Certo momento Eder chegou ao local e foi recebido por Sidneya, que estava com uma sacola plástica na mão, e após conversarem esta retirou dois “kits” de cocaína embalados em plástico transparente e os entregou à Eder, que por sua vez seguiu em direção a um ponto de venda de droga, conhecido vulgarmente como “Miolo”. Ao ser abordado Eder colocou no interior da boca os dois kits de cocaína que havia recebido de Sidneya, cada kit continha 15 (quinze) eppendorfs de cocaína, totalizando 30 (trinta), e em busca pessoal foi encontrado o valor de R\$ 72,00 (setenta e dois reais) em notas diversas e um aparelho celular, que estavam dentro de uma pochete. Eder confessou ter pegado a droga com Sidneya e que iria comercializar cada porção por R\$ 10,00 (dez reais). Diante desses fatos, foram para a casa de Sidneya e pela fresta do portão a viram mexendo em um kit de drogas dentro da mesma sacola vista anteriormente, razão pela qual ingressaram no imóvel. Sidneya correu para o interior da casa e tentou dispensar a droga pelo vaso sanitário, todavia foi impedida pelos policiais, que retiraram do vaso a sacola que continha 2 (dois) kits com cocaína, sendo um com 15 (quinze) eppendorfs e outro com 16 (dezesseis) eppendorfs e mais 11 (onze) kits de crack, sendo 10 (dez) destes com 10 (dez) pedras e 1 (um) kit contendo sete pedras. Além disso, em cima do fogão da cozinha de Sidneya os policiais encontraram o valor de R\$439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em notas diversas e um aparelho celular.

A caracterização da traficância restou evidenciada, não se mostrando necessária a efetiva visualização da venda, pois o tipo penal admite outras condutas além de vender, dentre elas estão “trazer consigo, guardar e ter em depósito”.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente (RT 776/663)". Ressalta-se que Eder foi preso em local de intenso tráfico de entorpecentes, onde ocorrem inúmeras prisões por tráfico diariamente, fato de conhecimento notório local.

Os depoimentos dos policiais foram uníssonos e coerentes, não apresentaram quaisquer divergências, todas as questões levantadas pela defesa foram respondidas de forma coerente.

Em busca pessoal em Eder foram localizados 02 (dois) “kits” contendo 15 (quinze) eppendorfs de cocaína cada, totalizando 30 (trinta) eppendorfs, além de R\$ 72,00 (setenta e dois reais) em notas diversas e um aparelho celular. Já na residência de Sidneya foram apreendidos 02 (dois) kits contendo cocaína, sendo um com 15 (quinze)

eppendorfs e outro com 16 (dezesesseis) eppendorfs e mais 11 (onze) "kits" de crack, sendo que 10 (dez) kits continha 10 (dez) pedras e 01 (um) kit contendo 07 (sete) pedras, além do valor de R\$439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em notas diversas e um aparelho celular.

Em seu interrogatório em solo policial a corré Sidneya confessou estar guardando entorpecentes em sua residência a pedido de Eder, bem como confirmou que foi pega pelos policiais com a mão na sacola onde estavam os entorpecentes e que o dinheiro apreendido em sua residência é fruto do tráfico de drogas. Em juízo, ambos os acusados confessaram o tráfico de drogas.

A quantidade de entorpecentes (61 porções de cocaína e 107 pedras de "crack"), a forma como estavam acondicionados (divididos em kits), os valores apreendido (R\$ 72,00 com Eder e R\$ 439,00 com Sidneya), aliados às circunstâncias da prisão, bem como o fato dos policiais já terem conhecimento do envolvimento dos acusado com o tráfico, não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.

Assim, considerando as circunstâncias em que os réus foram presos e as provas produzidas em juízo, impõe-se a aplicação das penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao delito de associação ao tráfico:

A associação para o tráfico, conduta prevista no artigo 35 da Lei de Drogas não restou provada nos autos, pois não se demonstrou a existência do animus associativo, com caráter de habitualidade, estabilidade e organização, mas sim mera convergência ocasional de condutas, caracterizadora apenas da coautoria e não da associação, entre Sidneya e Eder.

Dos depoimentos prestados em juízo, não foi possível extrair a comprovação de um verdadeiro liame subjetivo entre o os acusados para a prática do tráfico. Muito embora os policiais tenham se referido que Sidneya entregou entorpecente para Eder vender, não há indício de sociedade, associação ou animo associativo exigido para a configuração do delito.

Muito embora haja divergência nas versões dos réus, não há provas de organização, liame associativo. As provas dos autos apontam o fornecimento de drogas e pagamento pelos kits, cujo lucro seria auferido por Eder.

Além disso, os policiais militares afirmaram que nas denúncias previas no havia relatos do envolvimento de Eder. Portanto, há pelo menos dúvida quanto a associação, eis que não há qualquer evidência concreta de que praticam tráfico de entorpecentes juntos, embora haja indícios nesse sentido, não há provas para corroborar com essa afirmação e que possam ser utilizadas para fins de se comprovar alguma estabilidade que se exige para a associação.

A parcial procedência da ação penal é medida de rigor, pois os réus deverão ser absolvidos da imputação do artigo 35 da Lei de Drogas.

Passo a dosimetria da pena.

A quantidade e diversidade de droga são critérios que podem ser utilizados tanto elevação da pena base, por aplicação dos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, quanto para dosar a diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da lei de Drogas, em razão de ausência de critérios legais específicos para se dosar a maior ou menor de diminuição. Em qualquer circunstância não será possível a utilização dos mesmos critérios na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Assim, considerando que a causa de diminuição de pena é critério preponderante sobre as circunstanciais judiciais, a quantidade e diversidade de entorpecentes serão considerados na terceira fase de aplicação da pena.

Quanto a ré Sidneya de Jesus Vicente:

Na primeira fase, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, deve ser fixada no mínimo legal, a ré é tecnicamente primária e não há

elementos para se aferir possuir maus antecedentes (fl. 50), contudo, a quantidade expressiva de drogas apreendidas, considerando ainda potencialidade lesiva das substância, bem como a diversidade de drogas, justificam aplicação da pena acima do mínimo legal, devendo a pena-base ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual a pena deve retornar ao patamar mínimo, para ser fixada nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou de diminuição. Verifica-se pela certidão de fls. 56 que a ré, muito embora seja tecnicamente primária, está envolvida na prática do tráfico de drogas, responde processo por fato idêntico (1500808-07.2022.8.26.0180). Além disso, há relatos dos policiais que há tempos a ré estava fornecendo drogas para os traficantes da Vila São Pedro. Há, portanto, provas de se dedicava anteriormente aos fatos a atividades criminosas, justificando o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, (redação conforme Lei 11.464/2007).

Não havendo mais circunstâncias a considerar, torno a pena definitiva aplicada.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não presentes os requisitos legais.

Quanto ao réu Eder Maciel Lopes:

Na primeira fase, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes (fls. 43/49), razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fls. 43/49), devendo haver a compensação, para manutenção da pena no patamar anterior.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, (redação conforme Lei 11.464/2007).

O crime em concreto praticado pelos réus é deveras grave e, por isso mesmo, nem guardam compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem

atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 – São José do Rio Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Salles Abreu – 04/10/2011).

E ainda:

PENA – Restritivas de direitos – Tráfico de entorpecentes – Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) – Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 – Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 17/08/2006 – V.U.).

PENA – Restritivas de direitos – Réu condenado por tráfico de entorpecentes – Substituição da reprimenda privativa de liberdade – Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 – São Paulo – 9ª Câmara Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 27/09/2006 – V.U.).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para: (i) CONDENAR a ré SIDNEYA DE JESUS VICENTE, RG: 59.814.214, nascida em 26/07/2001, filha de Sidney Vicente e Rita de Cassia de Jesus, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, sem substituição; (ii) CONDENAR o réu EDER MACIEL LOPES, RG: 43.439.666, nascido em 07/07/1985, filho de José Maciel Lopes e Maria Aparecida Romualdo Martins, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, sem substituições; e para (iiii) ABSOLVER os réus SIDNEYA DE JESUS VICENTE e EDER MACIEL LOPES da imputação do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Subsistindo os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do réu, em especial a ordem pública, tendo em vista a reiteração da conduta e possibilidade de se furtarem a aplicação da lei penal, entendo que os réus Eder e Sidneya deverão permanecer presos cautelarmente.

Reconhecido o tráfico, de rigor o decreto de perda dos valores apreendidos em favor da União.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, as expensas do condenado. Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados e oficie-se à SENAD, nos termos do art. 63, §4º da lei de 11.343/2006.

P.I.

Espírito Santo do Pinhal, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA